

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2013/4328

- Acusados:** Banco BTG Pactual S.A.
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Guilherme da Costa Paes
Mariana Botelho Ramalho Cardoso
- Ementa:** Eventual responsabilidade por falha informacional no prospecto definitivo de distribuição de cotas de Fundo de Investimento Imobiliário. *Absoluções.*
- Decisão:** Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu **Absolver o Banco BTG Pactual S.A., a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, Guilherme da Costa Paes e Mariana Botelho Ramalho Cardoso** da acusação de infração ao disposto no art. 38, combinado com o art. 39, da Instrução CVM nº 400/2003.

Proferiu defesa oral o advogado Felipe Andreu Silva, representando o Banco BTG Pactual S.A. e a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator, Gustavo Tavares Borba e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2013/4328

- Acusados:** Banco BTG Pactual S.A.
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Guilherme da Costa Paes
Mariana Botelho Ramalho Cardoso
- Assunto:** Responsabilidade da Administradora, da Instituição Líder e de seus diretores por omissão nas informações prestadas no prospecto definitivo de oferta pública de distribuição de cotas de Fundo de Investimento Imobiliário – FII (art. 38 c/c art. 39, da Instrução CVM nº 400/2003).
- Relator:** Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE para apurar a responsabilidade do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Instituição Líder”) e seu diretor, Guilherme da Costa Pires (“Guilherme da Costa”), bem como da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (“Administradora” ou “Ofertante”) e sua diretora Mariana Botelho Ramalho Cardoso (“Mariana Botelho”), por omissões verificadas no prospecto definitivo da oferta pública da 4ª distribuição de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Fundo de Fundos (respectivamente, “Prospecto”, “Oferta” e “Fundo”), em infração ao disposto no art. 38¹, c/c o art. 39² da Instrução CVM nº 400/2003.
2. Este processo sancionador tem origem no Processo CVM nº RJ2012/12482, em que se analisou reclamação protocolada por M.J.T. (“Reclamante”) junto à CVM, em 9.10.2012, questionando as informações fornecidas por sua corretora, XP Investimentos CCTVM S.A. (“Corretora XP”), a respeito do prazo para o exercício do direito de preferência de subscrição de novas cotas do Fundo.

II. DOS FATOS

3. Em 9.10.2012, a CVM recebeu reclamação de M.J.T. (fl. 15), cotista do Fundo, em razão de este não ter conseguido exercer seu direito de preferência de subscrição de novas cotas. O Reclamante afirmou que, segundo o cronograma constante do Aviso de Distribuição Pública de Cotas do FII-BTG Pactual Fundo de Fundos, emitido em 28.9.2012, o prazo de encerramento do período de direito de preferência seria dia 10.10.2012.
4. No entanto, ao solicitar a subscrição de novas cotas junto à Corretora XP no dia anterior, em 9.10.2012, o Reclamante teria sido informado que o prazo para exercício do direito de preferência se encerrara em 8.10.2012 e que a data prevista no cronograma correspondia ao prazo para a liquidação financeira da operação.
5. Em 6.11.2012, a SRE³ solicitou a manifestação da Corretora XP, da Instituição Líder e da Administradora acerca do teor da reclamação. A Administradora apresentou resposta (fls. 25 a 28) em 21.11.2012, esclarecendo que, de acordo com o item 6 (Tabela de Prazos e Horários) do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC à época vigente (“Manual”), a data limite para subscrição dos direitos em ambiente de bolsa é V-2, ou seja, até dois dias antes do término do prazo para subscrição junto ao emissor dos ativos.
6. Dessa forma, a data de encerramento informada pela Corretora XP ao Reclamante (8.10.2012) referia-se à subscrição de cotas no ambiente da BM&FBOVESPA. Não obstante, segundo a Administradora, da leitura do Manual não restaria dúvida de que o direito de preferência poderia ser exercido perante a instituição escrituradora até 10.10.2012.
7. A Administradora acrescentou que *“embora entenda que estas informações sejam de acesso e conhecimento público, a Administradora pretende, nas próximas ofertas públicas de cotas dos fundos de investimento por ela administrada em que haja possibilidade de exercício do direito de preferência via BM&FBOVESPA ou escriturador, inserir informação nos documentos da oferta sobre esses procedimentos operacionais da*

BM&FBOVESPA, com o intuito de mitigar a possibilidade de ocorrência de situações como a descrita pelo Reclamante.” (fl. 26).

8. Em 10.12.2012, a Corretora XP informou que, na qualidade de intermediadora, teve que seguir o prazo estabelecido para reservas no Manual (8.10.2012) e que apenas as subscrições feitas perante o escriturador poderiam ser realizadas até o dia 10.10.2012 (fls. 29 a 30).

9. Em 10.1.2013, a SRE solicitou⁴ as manifestações da Administradora e da Instituição Líder acerca da obrigação estabelecida no art. 37, inciso VII, da Instrução CVM nº 400/2003⁵, segundo o qual a Instituição Líder deve participar ativamente da elaboração do Prospecto, em conjunto com o Ofertante, a fim de assegurar que as informações prestadas sejam suficientes para orientar o investidor a respeito da Oferta.

10. Os acusados apresentaram, em 18.1.2013, resposta conjunta (fls. 42 a 46), na qual alegam que não houve prejuízo para o Reclamante, tendo em vista que ele contou ainda com dois dias para exercer o direito de preferência junto à instituição escrituradora. Ademais, reiteraram a sua intenção de incluir informações sobre os procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA nas próximas ofertas públicas de cotas dos fundos de investimentos administrados pelo Ofertante ou intermediadas pelo BTG Pactual.

11. Diante das manifestações apresentadas, em 4.3.2013, a SRE encaminhou nova comunicação⁶ aos acusados com algumas considerações a respeito dos fatos já apurados. Em primeiro lugar, chamou atenção para o fato de não constar do Prospecto qualquer informação sobre a distinção de prazos para o exercício do direito de preferência no ambiente da BM&FBOVESPA ou por meio da instituição escrituradora. Ressaltou ainda que, embora a Corretora XP tenha afirmado que “*o cronograma publicado no Aviso de Mercado é meramente indicativo*” (fl. 29), de acordo com a Instrução CVM nº 400/2003, ele teria se tornado de cumprimento obrigatório a partir do momento em que tal cronograma foi confirmado no Prospecto, por força do art. 38 da referida Instrução.

12. A SRE afirmou, então, que a omissão nas informações prestadas pelos responsáveis pela oferta a respeito do prazo para exercício do direito de preferência teria induzido o investidor a erro ao acreditar que teria até o dia 10.10.2012 para fazer uso desse direito. Por fim, acrescentou que a declaração dos acusados de que, nas próximas emissões, pretendem incluir no prospecto informações referentes à distinção de prazos para a subscrição de cotas por meio da BM&FBOVESPA ou do escriturador indicaria que a Administradora e a Instituição Líder reconhecem o defeito das informações constantes do Prospecto.

13. Em resposta às considerações da SRE, apresentada em 7.3.2013 (fls. 54 a 59), a Administradora e a Instituição Líder informaram que entendem não ter havido violação ao art. 38 da Instrução CVM nº 400/2003, pois as informações necessárias para compreensão das condições da Oferta constavam do Prospecto. Ademais, o prazo estabelecido para exercício do direito de preferência foi concedido até a data prevista, tendo sido dada oportunidade a todos os cotistas do Fundo, inclusive ao Reclamante, de exercerem esse direito até 10.10.2012. Afirmaram ainda que, procurados por e-mail pelo Reclamante em 9.10.2012 (fls. 61 a 64), instruíram-no corretamente sobre a possibilidade de exercício do direito de preferência no escriturador até o dia 10.10.2012.

14. No que concerne à alegação da SRE de que o Reclamante teria sido induzido a erro pelas informações contidas no Prospecto, os acusados afirmaram que, considerando os 2.807 cotistas anteriores do Fundo que exerceram o seu direito de preferência tanto no âmbito da BM&FBOVESPA quanto no escriturador, *"não há como afirmar que uma reclamação isolada (ou mesmo pouquíssimas reclamações) resulte na conclusão de que os investidores foram induzidos a erro (...). Pelo contrário, o efetivo exercício do direito de preferência por diversos cotistas no âmbito da Oferta afasta essa tese."* (fl. 56).

15. Por fim, a Administradora e a Instituição Líder esclareceram que a declaração de que pretendem, nas próximas ofertas públicas de cotas dos fundos de investimento por eles administrados, inserir informações sobre os procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA não importa reconhecimento do defeito nas informações do Prospecto, mas sim a verificação de que essa matéria merece maior destaque nos documentos das suas futuras ofertas públicas.

16. Em resposta à solicitação da SRE⁷, protocolada em 27.3.2013 (fls. 67 e 68), a Instituição Líder informou que o Reclamante não subscreveu a Oferta e, portanto, não exerceu o direito de preferência via escriturador. Ademais, informou que um total de 67 cotistas anteriores do Fundo exerceu o seu direito de preferência via escriturador, sendo que, dentre eles, 35 o fizeram nos dias 9 e 10.10.2012.

17. Ademais, a área técnica apurou que os acusados Mariana Botelho e Guilherme da Costa, diretores estatutários, respectivamente, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e do Banco BTG Pactual S.A., eram os administradores responsáveis pela Oferta.

III. DA ACUSAÇÃO

18. Diante dos fatos acima apurados, a SRE apresentou, em 25.4.2013, termo de acusação⁸ (fls. 1 a 13) em face da Administradora, de Mariana Botelho, do BTG Pactual e de Guilherme da Costa por irregularidades relativas à prestação de informações no âmbito do Prospecto da Oferta.

19. A acusação destacou que o art. 38 da Instrução CVM nº 400/2003 exige que as informações do Prospecto sejam completas, precisas, verdadeiras, atuais, claras, objetivas e necessárias. Dessa forma, se observadas estas exigências, o investidor não necessitaria consultar documentos externos ao Prospecto para se informar a respeito das ofertas. A SRE apontou, no entanto, que não constava do Prospecto a informação que os prazos para exercício do direito de preferência seguiam os procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA e que, em decorrência desses procedimentos, entre os dias 9 e 10.10.2012, o direito de preferência só poderia ser exercido por meio do escriturador.

20. Segundo o entendimento da SRE, o fato de a informação constar do Manual não justificaria a sua omissão no Prospecto, tendo em vista que, além do Manual ser um documento de difícil manuseio, há no Prospecto uma série de outras informações de acesso e conhecimento públicos, mas que se mostram necessárias ao conhecimento da Oferta. Diante disso, seria natural, além de necessário, que o Prospecto mencionasse o referido Manual e fornecesse o endereço eletrônico disponível para conhecimento do seu conteúdo ou que informasse diretamente que, entre os dias 9 e 10.10.2012, o direito de preferência só poderia ser exercido por meio do escriturador.

21. A acusação apontou ainda que o desconhecimento do procedimento para o exercício do direito de preferência nos dias 9 e 10.10.2012 levou o Reclamante a erro,

configurando infração ao disposto no art. 39 da Instrução CVM nº 400/2003. O fato de o Reclamante só ter tido conhecimento deste procedimento após troca de e-mails com a Instituição Líder indica que esta informação deveria constar originalmente do Prospecto, de modo que os investidores pudessem se programar para evitar qualquer tipo de dificuldade no comparecimento à agência do escriturador.

22. De acordo com o entendimento da SRE, *"o desconhecimento dessa informação crucial fez com que o Reclamante não conseguisse exercer o seu direito de preferência, não lhe tendo sido possível ir pessoalmente até a agência do escriturador que realizava esse serviço"* (fl. 10). Ademais, o fato de menos de 3% dos cotistas que exerceram o seu direito de preferência o terem feito por meio do escriturador indicaria que este não é o ambiente mais prático e procurado pelos investidores para subscrição de novas cotas.

23. Com base em análise da cotação das cotas do Fundo na BM&FBOVESPA no início e no final da data de encerramento do exercício do direito de preferência, a SRE apontou ainda que o não exercício do direito de preferência acarretou ao Reclamante a perda de oportunidade de eventual obtenção de lucro na faixa de 25%.

24. Sendo assim, considerando que a responsabilidade pela deficiência nas informações prestadas no Prospecto da Oferta recai, por força do disposto no art. 56, *caput* e §1º, da Instrução CVM nº 400/2003⁹, sobre o Ofertante e a Instituição Líder, e igualmente sobre os respectivos diretores estatutários responsáveis pela Oferta, por força do previsto nos artigos 56-A¹⁰ e 56-B¹¹ da referida Instrução, a Administradora, o BTG Pactual, Mariana Botelho e Guilherme da Costa foram acusados de descumprimento ao disposto no art. 38, c/c o art. 39, ambos da Instrução CVM nº 400/2003, considerada infração grave nos termos do art. 59, I12, da mesma Instrução e do art. 11, §3º, da Lei nº 6.385/1976¹³.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

25. Em 10.5.2013, a Procuradoria Geral Especializada – PFE¹⁴ entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6º¹⁵ e 11¹⁶, da Deliberação CVM nº 538/2008, sugerindo apenas que fosse alterada a descrição da tipificação da conduta, passando a constar a infração ao disposto nos artigos 38, c/c o 39, da Instrução CVM nº 400/2003, de forma a evidenciar que se tratava de infração única (fls. 75 a 79). A SRE acolheu as sugestões e, em 22.5.2013, alterou o Termo de Acusação (fls. 82 a 94), na forma descrita acima.

26. A PFE ressaltou ainda que

"Embora o Termo de Acusação tenha se prendido ao exemplo do investidor reclamante, fazendo referência ao suposto dano por ele sofrido, deve-se ressaltar que eventual violação ao disposto nos apontados artigos da Instrução CVM nº 400/2003 não depende de comprovação efetiva de dano por parte de qualquer investidor específico. Trata-se, com efeito, de norma de disclosure que tem como objeto a proteção de todos os investidores, indistintamente, ou seja, do mercado como um todo. Não há, portanto, que se ponderar acerca da existência ou não de dano efetivo ao reclamante, mas sim se houve ou não falha na divulgação da informação."

V. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM Nº SP2012/475

27. Em 30.10.2012, foi protocolada nova reclamação junto à CVM (fls. 175 e 176), com conteúdo similar ao da que deu origem ao presente processo administrativo sancionador, questionando as informações repassadas pela Corretora Alpes CCTVM S.A

("Corretora Alpes") a respeito do período para exercício do direito de preferência na subscrição de cotas da 4ª distribuição de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Fundo de Fundos. Esta nova reclamação resultou na instauração do Processo CVM nº SP2012/475.

28. O investidor A.A.K. ("Segundo Reclamante") relatou que, ao tentar exercer o seu direito de preferência na subscrição de cotas do Fundo, nos dias 9 e 10.10.2012, fora informado pela Corretora Alpes que o prazo se encerrara em 8.10.2012, a despeito do cronograma constante do Anúncio de Início de Distribuição informar que o prazo se encerraria apenas em 10.10.2012. Após questionamentos formulados pelo Segundo Reclamante (fls. 177 e 178), a Corretora Alpes alegou que *"o ocorrido se deu por razão de diversas mudanças no quadro de cronograma do BTG."* (fl. 178). Diante das alegações da Corretora Alpes, o Segundo Reclamante entrou em contato telefônico com a Ofertante, tendo sido informado de que poderia exercer o seu direito de preferência até o dia 10.10.2012 (fl. 177).

29. A CVM encaminhou comunicações solicitando esclarecimentos à Corretora Alpes e à Ofertante (fls. 198 e 199). Em resposta (fls. 201 e 202), a Corretora Alpes informou que, por não ter participado da Oferta como corretora integrante do consórcio de distribuição, não poderia realizar diretamente a reserva do direito de preferência dos clientes, mas somente encaminhar a solicitação à Instituição Líder ou obter informações junto a ela. Nesse sentido, tendo o Segundo Reclamante solicitado a subscrição de novas cotas após o prazo informado pela Instituição Líder, a Corretora Alpes teria se limitado a cumprir as suas determinações. Ademais, o próprio sistema CBLCNet informava como "Data fim do exercício" o dia 8.10.2012.

30. A Ofertante apresentou manifestação (fls. 245 a 247) apontando que, conforme consta do Manual, para subscrição no ambiente BM&FBOVESPA, o cotista deveria exercer o seu direito de preferência até dois dias antes do término do prazo do emissor. Ressaltou ainda que a Corretora Alpes teria se equivocado ao informar ao cotista que o prazo para subscrição de novas cotas do Fundo teria se encerrado em 8.10.2012 em decorrência de uma mudança no quadro de cronograma da Administradora.

31. Em 26.9.2013, o Diretor Otávio Yazbek, então relator deste processo sancionador, proferiu despacho (fls. 172 e 173) determinando a inclusão de cópia do Processo Administrativo CVM nº SP2012/475 aos autos e a abertura do prazo de 30 dias para que os acusados pudessem se manifestar sobre os novos documentos. O Termo de Acusação não foi alterado, pois, conforme ressaltado pela PFE e reiterado pelo Diretor, não seria necessária reclamação (ou dano) para configurar a infração objeto deste processo.

32. Em 4.11.2013, os acusados apresentaram aditamento à sua defesa, cujos argumentos serão descritos a seguir, em conjunto com aqueles trazidos na primeira versão de sua defesa.

VI. DAS DEFESAS

33. A Administradora, BTG Pactual, Mariana Botelho e Guilherme da Costa apresentaram defesa e o devido aditamento conjunta e tempestivamente nos dias 1.7.2013 e 4.11.2013, respectivamente (fls. 157 a 168 e 273 a 285).

34. Em síntese, segundo os acusados, não houve violação ao art. 38, c/c o art. 39 da Instrução CVM nº 400/2003, pois todas as informações necessárias para a

compreensão das condições da Oferta foram disponibilizadas aos investidores por meio do Prospecto. No que diz respeito ao prazo para exercício do direito de preferência, as informações constantes do Prospecto estavam corretas e a data informada foi respeitada, tendo sido dada a oportunidade a todos os antigos cotistas do Fundo de exercer esse direito até o dia 10.10.2012.

35. Ainda que não haja menção expressa ao Manual no Prospecto, há referências ao *"procedimento operacional da BM&FBOVESPA"* e às *"normas da BM&FBOVESPA"*, o que indicaria que estes regulamentos se aplicariam à Oferta. Conforme alegado pelos acusados, a não inclusão da descrição do Manual no Prospecto justificar-se-ia *"na medida em que há uma série de outros procedimentos que possuem relevância no âmbito da Oferta e a menção a apenas um deles poderia fazer com que os investidores interpretem que se trata do único documento que possui algum aspecto relevante."* (fl. 159).

36. Com relação à alegação da acusação de que as informações do Prospecto deveriam dispensar o investidor do conhecimento de documentos externos àqueles apresentados no âmbito da Oferta, os acusados sustentaram que, tal como ocorre com relação a alguns documentos do próprio emissor, mencionados no Prospecto, deveria bastar uma simples referência aos procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA para instruir os investidores.

37. De acordo com o entendimento dos acusados, as informações acerca do prazo para exercício do direito de preferência foram corretamente prestadas no Prospecto. A dificuldade na subscrição de novas cotas relatada pelo Reclamante teria sido ocasionada, portanto, pela orientação equivocada repassada pela Corretora XP, que o informou que o prazo havia se encerrado em 8.10.2012. Ainda assim, segundo os acusados, a Instituição Líder, após ser procurada por e-mail pelo Reclamante e observando o dever de diligência dela exigido, o instruiu corretamente sobre a possibilidade do exercício do direito de preferência por meio do escriturador até o dia 10.10.2012.

38. Nesse tocante, sustentaram que o Reclamante foi informado em tempo hábil de exercer o seu direito de preferência via escriturador e que a alegação que este não representaria o ambiente mais prático e procurado pelos investidores para subscrição de cotas do Fundo não deveria prosperar. Apontaram que tal alegação não levou em consideração o fato de a maior parte das cotas do Fundo estar custodiada na BM&FBOVESPA. Considerando ainda que, do total de cotistas anteriores do Fundo com direito ao exercício da preferência via escriturador, 46,85% aderiram à Oferta, os acusados afirmaram que o exercício do direito de preferência via escriturador seria um ato de simples execução.

39. Quanto à alegação de que o Reclamante teria sido induzido a erro pela omissão nas informações prestadas pelo Prospecto, reiteraram que uma reclamação individual, em um universo de 2.807 cotistas anteriores do Fundo que exerceram o seu direito de preferência, não poderia levar à conclusão de que os investidores foram levados a erro.

40. Com relação à suposta perda de oportunidade de lucro pelo Reclamante, destacaram que tal entendimento presume que o Reclamante teria vendido imediatamente as cotas adquiridas caso as tivesse subscrito, o que poderia não ter ocorrido, seja porque ele só estaria autorizado a aliená-las após a publicação do anúncio de encerramento da Oferta, em 26.11.2012, seja porque a sua intenção poderia ser diversa.

41. Reafirmaram sua intenção de incluir, nas próximas ofertas públicas de cotas dos fundos de investimento administrados pela Administradora ou intermediadas pela Instituição Líder, informações sobre os procedimentos operacionais da BM&FBOVESPA, o que não representaria, no entanto, o reconhecimento da falha nas informações prestadas pelo Prospecto. Os acusados acrescentaram que mantêm o seu entendimento de que tais informações têm natureza complementar, sendo dispensáveis para o correto entendimento dos investidores.

42. Enfim, sustentaram que, caso se entenda haver algum tipo de infração por parte dos acusados, esta não poderia ser considerada infração grave, nos termos do art. 59, inciso I, da Instrução CVM nº 400/2003. O aludido dispositivo fala em "*distribuição que se esteja processando em condições diversas das constantes no registro*", o que, segundo os acusados, não teria ocorrido, tendo em vista que a distribuição pública foi realizada de acordo com as informações constantes do Prospecto.

43. Já no âmbito dos aditamentos às defesas, os acusados se manifestaram sobre a segunda reclamação que deu origem ao Processo Administrativo CVM nº SP2012/475, reiterando grande parte dos argumentos já expostos e acrescentando que a informação quanto à diferenciação dos prazos para exercício do direito de preferência no ambiente de bolsa e no escriturador não estava presente em ofertas de fundos de investimento imobiliário realizadas por outros participantes do mercado. Os acusados ressaltaram que a divulgação dessas informações não poderia ser considerada um padrão no mercado de ofertas de fundos de investimento imobiliário.

44. Por fim, sustentaram que a responsabilização pelos eventuais prejuízos causados aos Reclamantes deveria recair sobre as corretoras, pois estas não souberam orientar corretamente os Reclamantes, repassando as instruções que receberam dos Acusados.

VII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

45. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 9.7.2013, o Diretor Otavio Yazbek foi sorteado como relator deste processo. Tendo em vista o término do mandato do Diretor em 31.12.2013, o processo foi redistribuído à Diretora Ana Novaes em 7.1.2014. Em 27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/2008.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ "Art. 38. Prospecto é o documento elaborado pelo ofertante em conjunto com a instituição líder da distribuição, obrigatório nas ofertas públicas de distribuição de que trata esta Instrução, e que contém informação completa, precisa, verdadeira, atual, clara, objetiva e necessária, em linguagem acessível, de modo que os investidores possam formar criteriosamente a sua decisão de investimento."

² "Art. 39. O Prospecto deverá, de maneira que não omita fatos de relevo, nem contenha informações que possam induzir em erro os investidores, conter os dados e informações sobre:
I - a oferta;
II - os valores mobiliários objeto da oferta e os direitos que lhes são inerentes;
III - o ofertante;
IV - a companhia emissora e sua situação patrimonial, econômica e financeira;

V - terceiros garantidores de obrigações relacionadas com os valores mobiliários objeto da oferta; e
VI - terceiros que venham a ser destinatários dos recursos captados com a oferta.”

³ Ofícios CVM/SOI/Nº 906, CVM/SOI/Nº910 e CVM/SOI/Nº911, respectivamente (fls. 17, 19 e 23).

⁴ Ofícios CVM/SER/Nº10/ 2013 e CVM/SRE/Nº11/2013, respectivamente (fls. 34, 35, 40 e 41).

⁵ “Art.37. Ao líder da distribuição cabem as seguintes obrigações: (...) VII – participar ativamente, em conjunto com o ofertante, na elaboração do Prospecto (art. 38) e na verificação da consistência, qualidade e suficiência das informações dele constantes, ficando responsável pelas informações prestadas nos termos do art. 56, § 1º;”

⁶ Ofício/CVM/SRE/Nº130/2013 (fls. 47 a 51).

⁷ Ofício/CVM/SRE/Nº179/2013 (fl. 65).

⁸ Em 22.5.2013, o Termo de Acusação original foi alterado apenas para modificar a descrição da tipificação da conduta, acolhendo a sugestão da Procuradoria Federal Especializada no sentido de combinar os artigos 38 e 39 da Instrução CVM nº 400/2003, a fim de deixar claro que se trata de apenas uma infração.

⁹ “Art. 56. O ofertante é o responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a distribuição.

§1º A instituição líder deverá tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que:

I - as informações prestadas pelo ofertante são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta; e

II - as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da companhia e as constantes do estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento, se aplicável, que venham a integrar o Prospecto, são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta. (...)”

¹⁰ “Art. 56-A. Os administradores da instituição líder da oferta, dentro de suas competências legais e estatutárias, têm o dever de zelar pelo cumprimento das obrigações impostas ao líder por esta Instrução.”

¹¹ “Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.”

¹² “Art. 59. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, sem prejuízo da multa de que trata o §1º do mesmo artigo, a distribuição:

I - que se esteja processando em condições diversas das constantes no registro; (...)”

¹³ “Art. 11. (...) § 3º - Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidos em normas da Comissão de Valores Mobiliários.”

¹⁴ Memo nº46/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 75-79).

¹⁵ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

¹⁶ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no **caput** sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2013/4328

Acusados: Banco BTG Pactual S.A.

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Guilherme da Costa Paes
Mariana Botelho Ramalho Cardoso

Assunto: Responsabilidade da Administradora, da Instituição Líder e seus diretores, por omissão nas informações prestadas no prospecto definitivo de oferta pública de distribuição de cotas de Fundo de Investimento Imobiliário – FII (art. 38 c/c art. 39, da Instrução CVM nº 400/2003).

Relator: Diretor Pablo Renteria

VOTO

1. A acusação que recai sobre os acusados refere-se à eventual falha informacional no prospecto definitivo da 4ª distribuição de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Fundo de Fundos, cujo Anúncio de Início de Distribuição fora divulgado em 28.9.2012.
2. O Prospecto, em diversas passagens (páginas 11, 27 e 42), informou que os cotistas do Fundo dispunham do prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do primeiro dia útil após a publicação do Aviso de Início de Distribuição, para exercer o direito de preferência na subscrição de novas cotas. Além disso, constava do cronograma da Oferta disponível no Prospecto que o período de exercício do direito de preferência se iniciaria em 1.10.2012 e se encerraria em 10.10.2012.
3. No entanto, no curso da instrução deste Processo, restou incontroverso que o período para o exercício da preferência na subscrição de cotas em ambiente de mercado de bolsa havia se encerrado, em realidade, dois dias antes do divulgado no Prospecto (8.10.2012), tendo em vista o prazo de dois dias, estabelecido no Manual de Procedimentos Operacionais da CBLC, para a liquidação financeira da operação. O prazo anunciado no Prospecto era válido, somente, para a subscrição perante a instituição escrituradora das cotas do Fundo.
4. O Prospecto, portanto, não esclareceu que o prazo para o exercício do direito de preferência era diverso conforme o pedido do cotista fosse formulado em ambiente de bolsa ou perante a instituição escrituradora das cotas do Fundo. Também não informou que, nos dois últimos dias do prazo enunciado no Prospecto (8 e 9.10.2012), a subscrição somente poderia ser efetuada perante a instituição escrituradora.
5. Em vista disso, a Superintendência de Registros – SRE concluiu que a Ofertante e a Instituição Líder, assim como os respectivos diretores responsáveis pelo cumprimento da Instrução CVM nº 400/2003, teriam infringido o disposto no art. 38 da Instrução, segundo o qual o Prospecto deveria conter “*informação completa, precisa, verdadeira, atual, clara, objetiva e necessária, em linguagem acessível, de modo que os investidores possam formar criteriosamente a sua decisão de investimento*”. Também teriam violado o disposto no art. 39 da mesma Instrução, nos termos do qual o Prospecto não pode conter informação capaz de induzir o investidor a erro.
6. De fato, a informação divulgada no Prospecto não foi a mais adequada. Não tenho dúvida de que teria sido apropriado esclarecer que o prazo para exercer o direito de preferência no ambiente de bolsa se encerraria no dia 8.10.2012, de modo que, nos dias

9 e 10 subsequentes, o exercício somente seria possível perante a instituição escrituradora.

7. Resta, assim, configurada a falha informacional no Prospecto, a qual, a rigor, como apontado pela SRE, traduz irregularidade à luz do disposto nos artigos 38 e 39 da Instrução CVM nº 400/2003. Disso se seguiria, portanto, a penalização dos acusados, que, nos termos da Instrução CVM nº 400/2003, são responsáveis pela falha apurada.

8. No entanto, a CVM, na qualidade de órgão regulador de condutas do mercado de valores mobiliários, deve, no exercício da sua atividade sancionadora, guardar estrita observância ao princípio da proporcionalidade, *sob pena* de subverter aludida atribuição, desvinculando-a dos propósitos e valores a que deve se orientar, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.385/1976.

9. A atividade sancionadora deve, em outras palavras, ser exercida com seriedade e prudência, de modo a desestimular e coibir práticas atentatórias ao bom funcionamento do mercado de valores mobiliários, sem produzir, todavia, incentivos adversos para os participantes do mercado.

10. Nesse sentido, este Colegiado já teve a oportunidade de ressaltar que: *"(...) em qualquer processo sancionador, o papel do Colegiado vai além do exame da pertinência da acusação e da ocorrência dos fatos. É preciso verificar a significância da infração no caso concreto, de modo a dosar adequadamente a pena, ou mesmo não aplicá-la, quando irrelevante in concreto a falta"*¹.

11. No caso enfrentado neste processo, é inegável o fato irregular constatado pela SRE. Considero, porém, que ele carece da reprobabilidade e da relevância indispensáveis a justificar a sujeição dos acusados às penalidades previstas no art. 11 da Lei nº 6.385/1976.

12. Diversas razões peculiares ao caso me levam a esse entendimento. Em primeiro lugar, a falha informacional apurada, embora prejudicial ao exercício desembaraçado do direito de preferência, não comprometeu a capacidade dos investidores de formar criteriosamente a sua decisão de investimento, sendo este, a meu ver, o bem maior tutelado pelos artigos 38 e 39 da Instrução CVM nº 400/2003.

13. Observo, em segundo lugar, que, apesar de imprecisa e incompleta, a informação contida no Prospecto não estava errada, uma vez que era possível o exercício do direito de preferência perante a instituição escrituradora até o final do prazo indicado no Prospecto.

14. Ressalto, em terceiro lugar, que foi adequada a maneira pela qual os acusados reagiram após serem intimados pela SRE a prestar esclarecimentos, ainda durante o procedimento que antecedeu este processo sancionador. Com efeito, comprometeram-se a aprimorar a informação contida nos prospectos por ocasião das próximas ofertas de cotas de fundos administrados pela Ofertante ou distribuídas pela Instituição Líder, em que haja possibilidade de exercício de direito de preferência. Desse modo, os prospectos esclarecerão os procedimentos operacionais adotados pela CBLC, com vistas a indicar, precisamente, o prazo de que dispõem os cotistas para exercer a preferência.

15. Além disso, também me parece diligente a conduta da Ofertante e da Instituição quando, ainda durante a Oferta, no dia 9.10.2012, receberam mensagem eletrônica do

cotista M.J.T. questionando o encerramento do prazo para o exercício do direito de preferência. No mesmo dia, os acusados responderam, informando ao cotista que o direito de preferência poderia ser exercido até o dia seguinte perante a instituição escrituradora. Parece-me, do mesmo modo, que foram diligentes no atendimento do Segundo Reclamante, que, por meio de contato telefônico, foi orientado acerca da possibilidade de exercício do direito de preferência até o dia 10.10.2012, perante a instituição escrituradora.

16. São essas as razões, em suma, que me levam a entender que não seria razoável nem proporcional, em sede de processo administrativo sancionador, considerar a irregularidade informacional identificada no Prospecto suficiente para a aplicação de penalidades aos acusados.

17. Há, ainda, um ponto a ser enfrentado neste caso. De acordo com a SRE, o cotista M.J.T. teria sofrido danos em consequência da falha informacional contida no Prospecto, uma vez que teria perdido a oportunidade de subscrever cotas no âmbito da Oferta e revendê-las em seguida por preço superior.

18. Quanto a esse ponto, ressalto que a PFE, ao apreciar a legalidade do termo de acusação, manifestou-se nos autos no sentido de que a apreciação do eventual dano sofrido pelo cotista M.J.T. não seria relevante para o mérito deste processo sancionador, que diz respeito especificamente à violação de dispositivos regulamentares da Instrução CVM nº 400/2003.

19. Concorro com a posição da PFE. Ressalto, ademais, que o fato de a falha informacional ter causado dano a M.J.T., ou a qualquer outro cotista do Fundo, é fundamental em eventual ação judicial indenizatória. No entanto, no âmbito deste processo administrativo sancionador, o julgamento deve ser pautado, precipuamente, pela reprobabilidade e pela relevância da lesão ao bem jurídico tutelado pelas normas da CVM, as quais, como dito acima, não justificam, neste caso, a cominação de penalidades aos acusados.

20. A meu ver, antes mesmo de instaurado o processo sancionador, a atuação da SRE já havia alcançado o objetivo mais relevante neste caso, qual seja, o compromisso firmado pelos acusados em aprimorar a informação contida nos prospectos por ocasião das próximas ofertas de cotas de fundos administrados pela Ofertante ou distribuídas pela Instituição Líder. Dessa maneira, a SRE já havia desempenhado a relevante função de induzir os participantes do mercado a cumprirem plenamente a regulamentação vigente.

21. Ao analisar futuras ofertas públicas, caberá então à SRE verificar se os prospectos proveem informações completas e precisas sobre os modos e prazos de exercício de preferência. A meu ver, tal exame não deve limitar-se às ofertas realizadas ou intermediadas pelos acusados. Deve, em vez disso, abranger todas as distribuições públicas que envolvam, em condições análogas às examinadas neste caso, o exercício de direito de preferência ou de prioridade na subscrição de valores mobiliários.

22. Em suma, feito esse importante esclarecimento, voto pela absolvição de Banco BTG Pactual S.A., BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, Guilherme da Costa Pires e Mariana Botelho Ramalho Cardoso da acusação de infração ao disposto no art. 38, combinado com o art. 39, da Instrução CVM nº 400/2003.

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR

¹ PAS CVM nº RJ2005/033, julgado em 5.10.2005, trecho do voto proferido pelo Relator Presidente Marcelo Trindade.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/4328 realizada no dia 01 de setembro de 2015.

Eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor e Presidente da Sessão Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/4328 realizada no dia 01 de setembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do Julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela absolvição dos acusados, nos termos do voto do Diretor-Relator.

Encerro a Sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR